

次の【事例】及び【判旨】に関する後記1から5までの各【記述】のうち、正しいものを2個選びなさい。

【事例】

Xは、Aに電話を掛け、本来支払う必要のない違約金をAが支払わなければならない旨うそを告げた。Aはうそを見破ったが、警察官から、「だまされたふり作戦」（引き続き犯人側の要求どおりに行動しているふりをして犯人を現行犯逮捕しようとする捜査手法をいう。）に協力することを依頼された。Aはこれに応じ、現金を某所に送付するようというXの指示に従ったふりをして、現金の代わりに模擬紙幣が入った荷物を同所に向けて発送した。その後、被告人は、Xから、報酬を支払う約束の下に荷物の受領を依頼され、詐欺の被害金を受け取る役割である可能性を認識しつつ、これを引き受け、「だまされたふり作戦」が開始されたことを認識せずに、上記場所で同荷物を受領し、警察官に現行犯逮捕された。

【判 旨】

被告人は、本件につき、Xによる欺罔行為がされた後、「だまされたふり作戦」が開始されたことを認識せずに、Xと共謀の上、本件を完遂する上で欺罔行為と一体のものとして予定されていた受領行為に関与している。そうすると、「だまされたふり作戦」の開始の有無にかかわらず、被告人は、その加功前の欺罔行為を含めた本件につき、詐欺未遂罪の共同正犯としての責任を負うと解するのが相当である。

【記 述】

1. 【判旨】は、被告人に詐欺未遂罪の共同正犯が成立するには、前記荷物の受領行為自体に未遂犯として処罰すべき法益侵害の危険性が必要であり、その危険性の有無は、一般人が認識可能であった事情及び被告人が特に認識した事情に基づいて判断すべきという立場に立った上で、一般人は、Aが「だまされたふり作戦」に協力している事実を認識することが可能であったとの評価を前提としている。
2. 【判旨】に対しては、Aがうそを見破っている以上、被告人が関与した時点では、詐欺罪が既遂に至る可能性がなく、被告人が法益侵害の危険性を惹起したとはいえないとの批判が考えられる。
3. 【判旨】を前提とした場合、強盗罪における財物奪取行為のみに関与した者には、同罪の共同正犯の成立を認めることはできない。
4. 【判旨】は、欺罔行為と財物受領行為の一体性を根拠として、財物受領行為のみに関与した者について、詐欺罪の承継的共同正犯を認めるとの立場と矛盾するものではない。
5. 【判旨】によれば、被告人がXのAに対する欺罔行為の内容を認識していても、同欺罔行為を自己の犯罪の手段として積極的に利用する意思がない場合には、詐欺未遂罪の共同正犯の成立が否定される。

No161

R3-3

詐欺罪

正解

2、4 (順不同)

正答率

93%

本問の【事例】及び【判旨】は、最決平29.12.11（百選182事件）を素材とするものである。

1 誤っている

【判旨】は、「受領行為」につき本件詐欺を完遂する上で「欺罔行為と一体のものとして予定されていた」との理解を前提に、「だまされたふり作戦」の開始の有無にかかわらず、「欺罔行為」を含めて詐欺未遂罪の共同正犯の成立を認めているが、「受領行為」自体の実行行為性の有無（不能犯の議論）には言及していない。仮に【判旨】が、「受領行為」自体の実行行為性につき、その危険性の有無は、一般人が認識可能であった事情及び被告人が特に認識した事情に基づいて判断すべきという立場（具体的危険説）に立っていた場合でも、本記述のように、一般人はAが「だまされたふり作戦」に協力している事実を認識することが可能であったと評価すると、受領行為による犯罪実現の危険性への因果性が否定され、詐欺罪の実行行為性は否定されることになる（最決平29.12.11の第1審判決）。つまり、本記述の前提に立つと、【判旨】の結論とは異なる結論に至る。したがって、本記述は誤っている。

2 正しい

【事例】をみると、①XのAに対する欺罔行為、②Aがうそを見破る、③「だまされたふり作戦」として模擬紙幣を発送、④Xと被告人の共謀、⑤被告人による荷物受領、という時系列となっている。②の段階でAがうそを見破っている以上、被告人が関与した④⑤の段階では、被告人はAの現金をだまし取ることはできない。にもかかわらず、【判旨】は、詐欺未遂罪の共同正犯の成立を認めている。この【判旨】に対しては、Aがうそを見破っている以上、被告人が関与した時点では、詐欺罪が既遂に至る可能性がなく、被告人が法益侵害の危険性を惹起したとはいえないとの批判が考えられる。したがって、本記述は正しい。

3 誤っている

【判旨】は、詐欺未遂罪の共同正犯を肯定する前提として、被告人が「本件を完遂する上で欺罔行為と一体のものとして予定されていた受領行為に関与」したと述べている。これは、詐欺罪の保護法益が個人の財産であるところ、欺罔行為はこれを直接侵害するものではなく、欺罔行為を手段として錯誤に陥った者から財物の交付を受ける点に法益侵害性がある、すなわち、欺罔行為に加えて交付行為（受領行為）があって初めて結果が発生するのであって、構成要件上一連の複数の行為が予定されているという特色に着目したものともみることができる。強盗罪は結合犯であり、実行行為としてなされた暴行・脅迫に加えて財物奪取行為があって初めて結果が発生するものである。構成要件上一連の複数の行為が予定されている点では、詐欺罪と類似の特色を有するといえる。こうした詐欺罪と強盗罪の類似性を重視しつつ、【判旨】を前提とすると、強盗罪における財物奪取行為のみに関与した者には、同罪の共同正犯の成立を認めることができるといえる。したがって、本記述は誤っている。

4 正しい

【判旨】は、被告人が「本件を完遂する上で欺罔行為と一体のものとして予定されていた受領行為に関与」したと述べていることから、本記述のように、欺罔行為と財物受領行為の一体性を根拠として、被告人に詐欺未遂罪の共同正犯を認めたものと解し得る。よって、【判旨】は本記述の立場と矛盾するものではない。したがって、本記述は正しい。

5 誤っている

承継的共同正犯の成否については、大別して積極説、消極説、中間説があり、中間説の代表的なものとして、後行者が先行者の行為を認識し、かつこれを自己の犯罪の手段として積極的に利用する意思がある場合に限り承継的共同正犯の成立を認めるものがある。しかし、承継的共同正犯の問題は、全ての犯罪類型に統一的な指針を見出すことは困難であり、犯罪の種別ごとの個別的検討の重要性が指摘されてきたところ、最高裁判所も特定の立場を採ることを明らかにしていない。【判旨】（最決平 29.12.11）でも、被告人に積極的な利用意思があったかどうかに触れることなく共同正犯の成立を肯定している。よって、本記述のように、【判旨】によれば、後行者に積極的な利用意思がない場合、詐欺未遂罪の共同正犯の成立が否定されることになるわけではない。したがって、本記述は誤っている。

以上により、正しい記述は2と4であり、したがって、正解は肢2と肢4（順不同）となる。